

1500866-29.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... DE PENA.

PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE

DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500866-29.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500866-29.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2123311 - DEL.POL.COTIA,

3088/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2123311 - DEL.POL.COTIA, 3088/19/403 - DEL.POL.COTIA,

2123311/2019 - DEL.POL.COTIA, 4956777 - DEL.POL.COTIA, 3088/19/403 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISMAEL RODRIGUES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Vistos.

ISMAEL RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi originariamente denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 28 de abril de 2019, por volta de 9h32min, na Rua Nova Friburgo, nº 207, Jardim Nova Cotia, Cotia/SP, trazia consigo, sem autorização legal e em desacordo com regulamentação legal ou regulamentar, para fins de mercancia, 46 (quarenta e seis) porções de maconha (104,2 g.), 38 (trinta e oito) porções de cocaína (15,6 g.) e 45 (quarenta e cinco) porções de crack (6,9 g.), drogas que determinam dependência física e psíquica.

Foi concedida liberdade provisória ao réu, nos termos da decisão de fls. 32/34.

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2019 (fls. 62/63), sobrevindo a citação (fl. 77) e a apresentação de resposta à acusação (fls. 79/89).

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia. Na sequência, promovido o aditamento da peça acusatória, para inclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, contra o qual a Defesa não ofereceu oposição e que foi recebido nos termos do artigo 384, §2º, do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos do aditamento da denúncia. No tocante à dosimetria, opôs-se ao reconhecimento da figura do privilégio, sobretudo ante a quantidade e natureza das drogas apreendidas, postulando, no mais, a fixação de regime prisional fechado. A Defesa pleiteou a fixação das penas no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a imposição de regime prisional semiaberto e o deferimento de eventual interposição de recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória comporta parcial acolhida.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), pelo laudo de constatação (fls. 23/25) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 68/71), que descreve o exame das substâncias apreendidas por métodos científicos apropriados e conclui, ao final, tratar-se da droga descrita na denúncia, substância elencada nas listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS n.º 344, de 1998, o que atrai, nas circunstâncias, a incidência da norma penal do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

A autoria da infração restou igualmente demonstrada, diante da prisão do réu em flagrante delito e sua indicação segura, sob o crivo do contraditório e à luz da prova oral produzida, como autor da prática criminosa exposta na denúncia.

A guarda civil municipal Anderson relatou, em juízo, que, na data dos fatos, visualizou o réu, em via pública, há cerca de cem metros de uma escola municipal, com uma pochete nas mãos. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir, mas foi perseguido e abordado. Durante a tentativa de fuga, arremessou a pochete, que foi posteriormente localizada e apreendida. No interior dela, foi encontradas porções de maconha, cocaína e crack. Nas vestes do réu, foi localizada a quantia de R\$ 45,00. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos.

O réu, por seu turno, confessou a imputação, acrescentando que a abordagem ocorreu no terceiro dia em que estava vendendo drogas. Na época, estava em situação de dificuldade financeira e sua esposa padecia de problema de saúde.

Pois bem. A confissão do réu no tocante à prática delitiva está em sintonia com os depoimentos do agente público ouvido em juízo, assim como com o auto de exibição e apreensão, o teor do laudo de constatação e o teor do exame químico-toxicológico.

Nesse contexto, não há nada a retirar a credibilidade da confissão espontânea do réu, na medida em que se harmoniza, como acima explicitado, com o restante da prova oral produzida sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo Penal) e com os demais elementos de instrução amealhados.

Prosseguindo, ficou suficientemente comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, conforme documento de fl. 106 e do depoimento do guarda civil municipal, que atesta a presença de estabelecimento de ensino (Escola Municipal Isabel Ribeiro Leal Leite) nas proximidades do local dos fatos.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado em ambas as Turmas Criminais do C. Superior Tribunal de Justiça, a causa modificativa prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, tem natureza objetiva, sendo suficiente ao seu reconhecimento que a infração tenha sido perpetrada nas dependências ou imediações de algum dos locais elencados em tal dispositivo legal:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA INSERTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA MERCANCIA NO REFERIDO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA MANTIDA.

Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, 'Para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os trabalhadores, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades' (AgRg no AREsp n. 730.717/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje de 23/3/2017).

Agravo regimental desprovido” (AgRg. no REsp. nº 187.9672/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 9/12/20, DJe 15/12/20).

“A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento” (REsp. nº 1.719.792/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13/3/18, DJe 26/3/18).

No mais, não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a sua punibilidade, de modo que a condenação pela prática de crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Passo, então, à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Na primeira fase da dosimetria, em razão da quantidade de drogas apreendidas, de tipos diversos, e da natureza especialmente nociva da parte delas (cocaína e cocaína sob a forma de crack), as penas são fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. Na etapa intermediária da dosimetria, presente a atenuante da confissão, as penas são reduzidas ao mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Na etapa derradeira da dosimetria, mostra-se aplicável o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a primariedade do réu (fls. 104/105) e a ausência de provas conclusivas no sentido de que se dedique a atividades criminosas, pelo que as sanções são diminuídas em 2/3 (dois terços), sendo inviável a valoração neste feito, desfavoravelmente ao réu, de eventos, ainda que ilícitos, ocorridos anos após os fatos apurados nos autos. Ainda na terceira fase, as reprimendas são aumentadas em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006. Penas definitivas fixadas em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, valor unitário correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a ausência de elementos que possibilitem valoração diversa quanto à

capacidade financeira do réu.

Anote-se que, consoante orientação sedimentada recentemente no âmbito da C. 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade de drogas, por si sós, não têm o condão de afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo, além disso, inviável a utilização, para modulação do quantum de diminuição, de circunstâncias já valoradas na primeira fase da dosimetria para fixação da pena-base:

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA.

PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeesse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença” (REsp. nº 1.887.511/SP, 3ª

Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 9/6/21, DJe 1º/7/21).

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo em conta a quantidade de pena privativa de liberdade imposta e a circunstância judicial preponderante valorada negativamente (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006).

Inadequadas a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, por força da já citada circunstância judicial negativa (artigos 44, III, e 77, II, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, ISMAEL RODRIGUES DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 33, §4º, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois assim permaneceu durante a tramitação do feito, inexistindo circunstâncias supervenientes que justifiquem a imposição de prisão preventiva neste momento.

Taxa judiciária pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, com fundamento no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, observada eventual gratuidade de justiça a ele deferida.

Certifique-se a incineração das drogas e o perdimento do numerário apreendido em poder do réu (fls. 6/7), nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Sentença proferida em audiência. Cumpra-se.

Cotia, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA